

与罪责刑相适应原则不符。

综上，如果将卖淫人员的获利分成计入容留卖淫者的非法获利数额，既与客观事实和双方的关系不符，又没有对卖淫人员的违法所得进行法律评价，且容易导致容留卖淫罪“情节严重”情形的滥用和整体的刑罚偏高。故，本案一审判决在认定被告人李某某容留卖淫犯罪非法获利数额时，将卖淫人员的嫖资分成部分扣除是适当的。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 蒋璟 杨柳

(八) 制作、贩卖、传播淫秽物品罪

直播平台上进行淫秽表演的行为应如何定性

——张某等传播淫秽物品牟利案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省定远县人民法院(2023)皖1125刑初132号刑事判决书

2. 案由：传播淫秽物品牟利罪

【基本案情】

被告人张某在开设网络赌房期间，明知平台女主播涉嫌淫秽表演，仍帮助平台对女主播进行管理。被告人张某旗下主播共牟利112105元。

被告人李某为牟取非法利益，自2021年6月上旬在某APP中注册成为家族代理，招募并管理被告人韩某、柳某（另案处理）等多名女主播进行淫秽表演，从中非法牟利84797元。被告人韩某自2021年6月上旬在某平台注册为“某家族”成员，进行网络直播淫秽表演，非法牟利5万元。

被告人马某某为牟取非法利益，自2021年11月起招募并管理被告人廖某、李某（另案处理）等多名女主播在“A”“B”等平台进行淫秽表演，从中非法牟利96900元。被告人廖某自2022年1月，在“A”“B”平台进行网络直播淫秽表演，非法牟利36000元。

【案件焦点】

张某等在网络平台上，以直播的形式进行淫秽表演的行为，应如何定性。

【法院裁判要旨】

安徽省定远县人民法院经审理认为：张某开设网络赌房期间，明知平台从事淫秽表演牟取非法利益，仍帮助平台进行管理；马某某、李某以牟利为目的，在网络平台招募廖某、韩某等人进行淫秽表演；被告人韩某以牟利为目的，在网络平台上进行淫秽表演；被告人廖某以牟利为目的，在网络平台上进行淫秽表演，被告人张某、马某某、李某、韩某、廖某的行为均构成传播淫秽物品牟利罪。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百六十三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用互

联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》第一条第一款第六项,第二条之规定,安徽省定远县人民法院判决如下:

一、被告人张某犯传播淫秽物品牟利罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币5万元;

二、被告人马某某犯传播淫秽物品牟利罪,判处有期徒刑三年,宣告缓刑四年,并处罚金人民币16万元;

三、被告人李某犯传播淫秽物品牟利罪,判处有期徒刑三年,宣告缓刑三年六个月,并处罚金人民币14万元;

四、被告人韩某犯传播淫秽物品牟利罪,判处有期徒刑三年,宣告缓刑三年,并处罚金人民币8万元;

五、被告人廖某犯传播淫秽物品牟利罪,判处有期徒刑一年十个月,宣告缓刑二年,并处罚金人民币5万元。

案件宣判后,判决已生效。

【法官后语】

1. 在网络平台上以直播的形式进行淫秽表演,所传递出来的信息具有淫秽性,侵害了社会善良道德风俗,具有严重的社会危害性,需要刑法予以规制。“直播淫秽表演”是指用户通过专门的网络直播平台将自己的身体部位裸露在摄像头下,并以大胆文字和动作通过网络传给对方的表演方式。

第一,同其他淫秽物品一样,直播淫秽表演的行为所传递出来的画面具有强烈的淫秽性。淫秽性是淫秽物品的本质属性。网络直播淫秽表演是一种通过网络摄像头,向特定或不特定的他人展示自己身体的行为。

第二,犯罪行为要符合“传播”的特点,将淫秽表演信息广为扩散,从而影响公众对于性的感情,具有严重的社会危害性,需要动用刑罚加以惩罚。传播是指通过播放、出租、出借、承运、邮寄等方式致使淫秽物品流传的行为,必须使不特定多数人能够获取或使用。利用网络直播进行淫秽表演的方式使人类的各种性行为公开化,违背了人类的性羞耻感,严重侵害了社会风尚中的善

良性风尚和性道德。一些不法分子利用这种直播淫秽表演方式,在网络直播平台设立家族长、招揽女主播,大肆组织网上淫秽表演,传播淫秽色情信息,非法牟利,严重影响青少年的身心健康,还诱发其他犯罪,具有严重的社会危害性,需要刑法予以规制。

2. 随着互联网的不断发展,合理扩张“淫秽物品”的含义,符合司法实践的实际需要,是刑法解释的要求所在,也没有违背罪刑法定原则。随着互联网技术的不断发展,淫秽信息本身以及淫秽信息的载体均在不断变化。我国刑事立法、司法解释也在根据社会的发展变化不断地对“淫秽物品”的认定范围进行相应调整。在1979年《中华人民共和国刑法》中,“淫秽物品”只有淫书、淫画两类;在1997年《中华人民共和国刑法》中,“淫秽物品”是指具体描绘性行为或者宣扬色情的淫秽性的书刊、影片、录像带、录音带、图片及其他淫秽物品。

随着互联网技术的发展,作为淫秽信息载体的淫秽物品不再具有直观的形式,而是通过网络在虚拟空间进行传播,速度更快,范围更广,对社会的危害更大。为进一步规制淫秽物品的范围,2004年发布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(一)》规定,“淫秽物品”是指具体描绘性行为或者露骨宣扬色情的淫秽性的视频文件、音频文件、电子刊物、图片、文章、短信息等互联网、移动通信终端电子信息和声讯台语音信息。2010年,又公布了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》,进一步打击淫秽电子信息犯罪。因此,面对法律的滞后性和局限性,我们要及时通过立法、司法解释和指导性案例来进行弥补,从而依法且及时地惩治犯罪。

由于受网络直播淫秽表演的技术特性所决定,视频信息往往是以及时的、动态的画面形式而存在,而并不附着于静态的文件载体之上,司法解

释对淫秽 信息的载体要求，使其难以有效应对此类电子淫秽信息带来的危害。随着电子

技术的发展，信息与信息载体的关系已经摆脱了传统模式的局限。在这种情况下，不应纠缠于信息有无载体这个问题，而应重点关注信息本身的内容是否具有淫秽性。例如，盗窃罪的犯罪对象从最初的有体物，发展到无体物，盗窃电力、煤气，盗接他人通信线路、复制他人电信号码，再到现在的盗窃他人网络虚拟财产。

综上所述，网络直播淫秽表演完全具备淫秽物品的基本属性，能够成为传播淫秽物品的犯罪对象。对于本案各被告人以牟利为目的，在网络上进行淫秽直播表演的行为，应当以传播淫秽物品牟利罪定罪处罚。

编写人：安徽省定远县人民法院 罗永新

二、贪污贿赂罪

55

私自截留非法捐赠的财物应定性为贪污，
贪污所得车辆及车辆贬值损失应一并上缴国库①

—— 王某某贪污案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

河南省驻马店市中级人民法院(2022)豫17刑初63号刑事判决书

2. 案由：贪污罪

【基本案情】

2014年1月，某公司向王某某所在单位捐赠一辆价值人民币55万元的中巴客车。王某某利用担任行政负责人的职务便利，安排人将该车登记在张某某实际控制的公司名下，交由其外甥刘某保管，供其个人及亲友使用。王某某同时实施了受贿罪犯罪事实和利用影响力受贿罪的犯罪事实。

【案件焦点】

1. 对于私自截留非法捐赠财物的行为，应定性为贪污罪还是受贿罪；2. 对

①入库案例，参见人民法院案例库2024-03-1-402-002。

涉案财物如何处置，是返还被害单位还是予以追缴、上缴国库；3. 涉案犯罪所得车辆是追缴车辆原物本身，还是车辆原物及车辆价值贬值损失。

【法院裁判要旨】

河南省驻马店市中级人民法院经审理认为：被告人王某某在担任某行政机关负责人期间，利用职务便利，将某公司捐赠给其单位的一辆价值55万元的中巴客车占为己有，安排将该车登记在他人公司名下供其个人及亲友使用，数额巨大，其行为已构成贪污罪。王某某自愿认罪认罚，并积极退赃，真诚认罪悔罪。据此判决：

一、被告人王某某犯受贿罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币180万元；犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币210万元；

二、被告人王某某受贿、利用影响力受贿、贪污犯罪所得的赃款、赃物依法予以追缴，上缴国库。已扣押退赃在案的人民币1377.65万元、美元2万元、港币5万元和赃物车辆五辆依法予以没收，上缴国库；剩余赃款(含车辆减损价值134.282021万元)，从查封在案的王某某购买并登记在贾某某名下的房产拍卖价款中继续追缴；在财产刑执行完毕后，如有剩余部分依法予以返还。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

一、私自截留捐赠财物的行为应定性为贪污

涉案中巴车系捐赠单位捐赠给被告人王某某所在单位的财物，从捐赠的初衷来看，本案捐赠单位为感谢受捐赠单位抢修其公司周边道路而捐赠一辆中巴车供其单位出行使用，其公司捐赠目的和受捐赠的主体是既定和确定的，受捐赠的主体系王某某所在单位而非王某某个人。公益事业捐赠合同属于诺成性合同，一旦作出不得随意撤销，捐赠的财物应归属于王某某所在单位，本案捐赠人已经作出捐赠的意思表示，受捐赠的主体亦同意接受，双方意思表示已经达成一致，该捐

二、贪污贿赂罪 233

赠合同已经成立并生效，涉案财物中巴车在法律上已成为王某某所在单位的财物。但王某某所在单位作为行政机关，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》的规定，依法不能接受捐赠。其违法接受捐赠，应当由相关纪检部门进